

1516008-75.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... descaracterizada a figura do tráfico, diante do demais elementos probatórios existentes.

Portanto, de rigor sua condenação nos termos acima.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, porque não há elementos que justifiquem seu aumento.

A agravante constante do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1516008-75.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516008-75.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS SALLES ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

MATHEUS SALLES ROCHA (RG 71954915-SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois teria, no dia 29 de julho de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 17h10, na Rua Tenente Sotomano, altura do nº 1.259, Bairro Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da capital, trazido consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo a substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 128,9g (cento e vinte e oito gramas e nove decigramas); 68 (sessenta e oito) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 31,4g (trinta e um gramas e quatro decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 4) e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 58/62). Foi apresentada defesa preliminar (fls. 102/107) e a denúncia foi recebida (fls. 113/114), sendo mantida a prisão preventiva.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas policiais, o réu foi interrogado e, ao final, a pedido da Defesa, foi determinada a instauração de incidente de dependência toxicológica, cujo laudo foi juntado em apenso (fls. 45 do Proc. 0000129-20.2021.8.26.0050).

Foi concedida liberdade provisória ao acusado, aplicando-lhe medidas cautelares (fls. 279/280).

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com elevação da pena base em metade, considerando a reincidência, e a fixação do regime fechado.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do instituto do tráfico privilegiado com a redução máxima; a aplicação da atenuante da menoridade relativa; o afastamento das agravantes da reincidência e da calamidade pública, assim como a aplicação na sentença da detração penal e fixação de regime aberto com substituição por medidas restritivas de direito de praxe, e apelação em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: auto de prisão em flagrante (fls. 4); boletins de ocorrência (fls. 11/13, fls. 14/15 e fls. 118/122); auto de exibição e apreensão (fls. 16); laudo de constatação (fls. 17/20); laudo toxicológico definitivo (fls. 91/93), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O laudo definitivo comprovou que as substâncias em posse do réu eram: 53 invólucros perfazendo 128,9g de massa líquida de Tetrahydrocannabinol (THC) e 68 invólucros 31,4g de cocaína.

O policial militar Rafael Oliveira Camara afirmou, em sede policial, que efetuava em patrulhamento com seu colega de farda Antonio, a bordo das motocicletas M-05390-11 e M-05384-11, e quando passavam pela Rua Tenente Sotomano, altura do nº: 1259, suspeitaram de um indivíduo andando a pé pela via, o qual, ao olhar a aproximação dos policiais, repentinamente mudou a sua direção. Desta forma ele foi abordado e não ofereceu nenhuma resistência, identificando-se como MATHEUS SALLES ROCHA. Na busca pessoal, o depoente e seu colega encontraram em sua cintura uma sacola plástica contendo 53 (cinquenta e três) invólucros com substância semelhante a maconha; e 68 (sessenta e oito) invólucros contendo substância semelhante a cocaína. Além disto, ele trazia consigo a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais). Ele não trazia consigo nenhum celular. Diante dos fatos ele foi detido e inicialmente conduzido ao 39ºDP - Vila Gustavo, onde as substâncias foram exibidas à Autoridade Policial que se achava de plantão.

Em Juízo, afirmou se recordar do réu. Disse que estavam em patrulhamento pela via quando se depararam com o indivíduo, o qual, ao avistar a equipe, mudou a direção que caminhava, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal foram encontradas as substâncias ilícitas e uma quantia em dinheiro, acredita que R\$ 80,00. Questionando o réu, este afirmou que estava praticando o comércio dos ilícitos, sendo então encaminhado ao DP. A testemunha ratificou que o réu estava portando maconha, cocaína e R\$ 80,00, e todas estavam divididas para venda, acopladas em sua cintura. Não sabe informar se ele tinha aparência de usuário. Disse que perguntou o que o réu estava fazendo com as drogas, e ele disse que estava vendendo. Não se recorda se disse isso na delegacia. Não disse nada além disso antes de questioná-lo. Não perguntou se o réu era usuário de drogas. Por fim, confirmou o réu como sendo a pessoa detida na ocasião dos fatos.

Extrajudicialmente, o policial militar Antonio Márcio da Rosa Júnior afirmou que realizava patrulhamento com seu colega de farda Rafael e, na Rua Tenente Sotomano, altura do nº: 1259, observaram um indivíduo em atitude suspeita, que caminhava pela via e, ao notar a presença das motocicletas policiais, demonstrou nervosismo e mudou a direção em que ia. Por conta disto resolveram abordá-lo e ele se identificou como MATHEUS SALLES ROCHA. Ele não ofereceu nenhuma resistência e, em seguida, foi submetido à busca pessoal. Na sua cintura foi encontrada uma sacola

plástica contendo 53 (cinquenta e três) invólucros com substância semelhante a maconha; e 68 (sessenta e oito) invólucros contendo substância semelhante a cocaína. Ele também estava na posse da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais). Nenhum celular foi encontrado com ele. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido primeiramente ao 39º DP, distrital da área dos fatos, onde a Autoridade Policial de plantão preliminarmente lavrou o BO nº: 1683/2020 para encaminhar as drogas ao Instituto de Criminalística. Em seguida, o depoente e seu colega apresentaram MATHEUS na delegacia.

Em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento com seu parceiro pela Rua Tenente Sotomano no bairro Jardim Brasil, quando o indivíduo avistou as viaturas e repentinamente, de modo muito suspeito, mudou a direção, o que chamou atenção da equipe. Em busca pessoal foi encontrado na cintura do réu o entorpecente e oitenta reais em espécie. Diante do fato, perguntaram ao Matheus sobre o ilícito, e ele admitiu estar na prática do tráfico de entorpecentes, sendo então conduzido ao DP onde se lavrou o auto de prisão em flagrante. A testemunha descreveu que as drogas que estavam com ele eram cocaína e "salvo engano" maconha. Ratificou que o réu confessou para a equipe. Aduziu que as drogas estavam dentro de uma sacola na cintura do réu, e estavam em invólucros separados. Sobre se antes de interrogá-lo disse algo para o réu, a testemunha afirmou que disse "Polícia, parado", tendo sido a abordagem padrão da PM, colocaram o indivíduo de costas para a equipe e fizeram a busca pessoal. Após encontrar os ilícitos, o interpelaram sobre o ilícito estar com ele. Depois de encontrar a droga, porém antes dele confessar, informou os direitos do réu, tendo relatado todos os fatos ao escrivão de polícia. Disse que o ilícito estava na cintura do réu e numa quantidade superior a quantidade do uso, em dinheiro trocado em espécie, relatou ao delegado e este lavrou o auto. Consultou os antecedentes do acusado. Por fim, informou que o réu é a mesma pessoa detida na ocasião dos fatos.

O acusado MATHEUS SALLES ROCHA se manteve em silêncio em seu interrogatório no auto de prisão em flagrante. Em Juízo, negou o crime. Afirmou que não é vendedor de droga, mas sim usuário. Disse que a droga que os policiais apresentaram não é dele. A única coisa que os policiais disseram que é verdade é que ele tinha o dinheiro na carteira, que também tinha foto dos familiares e seu alvará de soltura. Disse que estava de bicicleta, se despediu dos seus familiares que estavam numa casa no fundo de uma viela, e foi abordado pelos policiais que estavam de moto. Desceu da bicicleta, deitou no chão, foi algemado e ficou encostado na parede. Então os policiais desceram, foram na viela, voltaram, perguntaram se o réu tinha passagem, disse que sim e que estava na rua há 23 dias, então os policiais disseram "se faz 23 dias então é você mesmo". Disse que foram para a balada, e aí domingo, segunda, terça, quarta ficou usando droga, mas cansou e não tinha mais dinheiro para usar droga, então decidiu ir embora. Disse aos policiais que não tinha RG, mas que no alvará de soltura constava. Afirmou que então os policiais pegaram o alvará de soltura, e falaram "é isso daqui?" e então ele "picou" o alvará de soltura e afirmou que o réu estava preso. O réu disse que antes do policial ir na moto, ele mexeu no compartimento da moto, pegou uma sacola e pediu para ele segurar, ele falou que não ia segurar, então o policial mandou ele sentar na mão e cuspiu na sua cara, o jogou no chão e ficaram com o revólver em cima, dizendo "se você reagir você vai morrer aqui". O réu ficou esperando o pessoal sair da casa para avisar e explicar a situação, pediu para chamarem sua amiga Fabiana, afirmou que não segurou a sacola, e que não é dele essa droga, pois simplesmente estava na casa de uma amiga. O acusado disse que não estava em condições de responder porque estava em estado de choque, tinha usado muita cocaína e muito álcool, há 3 dias e 3 noites voltando da balada, domingo, segunda e terça, só na quarta que acabou. Afirmou que usa cocaína desde os 13 anos de idade, e que hoje é dependente químico, de maneira que "nada faz sentido se você não usufrui da droga". Afirmou que também fazia uso de doce, maconha, álcool, nicotina, lança perfume e que tudo começou no álcool. Afirmou que fez uso de DIAZEPAM durante dois anos durante sua adolescência, mas continuou usando drogas. Disse que os policiais perguntaram se ele usava droga, ele falou que sim, e o policial até falou "limpa o seu nariz que tá branco". Disse que está buscando a evolução espiritual e fé em Deus para se reeducar e tem certeza que

nunca mais vai usar drogas.

A quantidade de drogas apreendida, bem como sua variedade, demonstra que não se tratava o réu de mero usuário, tendo em vista a diversidade dos entorpecentes apreendidos, a sua quantidade totalmente desproporcional ao uso e o seu acondicionamento em pequenas porções, indicando a finalidade de distribuição a terceiros (tráfico). No mesmo sentido, o encontro de dinheiro em espécie sustenta tal autoria.

Importante aduzir que o depoimento dos policiais foi coeso, não existindo qualquer indício de que a fala dos agentes, os quais gozam de fé pública, seria para prejudicar a pessoa do réu, mas somente um relato dos fatos ocorridos. Nada demonstra que os agentes públicos quisessem prejudicar o réu, contando evento inexistente.

Outrossim, a versão do réu, que alegou não ser o dono da droga apreendida, e que há anos seria dependente químico, não encontra respaldo no laudo médico, que atestou não ser o acusado, à época dos fatos, dependente físico ou psíquico de substância entorpecente ou que determine dependência física e psíquica. Mesmo que o fosse, entretanto, ou se fosse apenas usuário de drogas, não estaria descaracterizada a figura do tráfico, diante dos demais elementos probatórios existentes.

Portanto, de rigor sua condenação nos termos acima.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, porque não há elementos que justifiquem seu aumento.

A agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "navrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "navrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "navrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavirus disease 19 - COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afastou a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular.

Reconheço a agravante da reincidência, porém deixo de aplicá-la, compensando-a com a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos.

Na terceira fase, tem-se como inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dada a reincidência do acusado. Não há causas de aumento de pena.

Assim, a pena final do réu será de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, ante a reincidência e quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, lido a contrario sensu. Ademais, trata-se de pessoa jovem, que o Estado deve procurar

buscar outros mecanismos para se restabelecer alternativas sociáveis de conduta. É o que se depreende da leitura sistemática de vários preceitos da Lei 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), especialmente nos artigos 2º inciso VI, 3º inciso XI e 38 inciso IV. Além disso, o Estado também deve buscar promover a reinserção social do acusado, que declarou ser usuário de drogas, o que acaba facilitando a sua introdução na rede do tráfico. Se a escolha for pela prisionização, portanto, que se faça pelo regime mais brando.

Inviável a substituição de penas em razão da reincidência e também por se tratar de condenação superior a 4 anos.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu MATHEUS SALLES ROCHA (RG 71954915-SP) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida nos termos dos artigos 1º, inciso III e 5º, inciso III, da Constituição Federal.

Deixa-se de aplicar a detração nessa oportunidade dada a situação do réu, que possui execução pendente, e permanece preso por outro juízo, conforme alvará de soltura cumprido com impedimento a fls. 310. Oportunamente, após ser expedida a guia de recolhimento, caberá à Vara de Execução competente promover a detração, se o caso.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei nº 11.343/06. P.I.C.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA